

1500038-05.2022.8.26.0280

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DIEGO FERREIRA DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

1500038-05.2022.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500038-05.2022.8.26.0280

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DIEGO FERREIRA DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta a denúncia que, em 25 de janeiro de 2022, por volta das 20h30, na Rua Joaquim Nardes de Águiar, nesta cidade e comarca de Itariri/SP, o acusado, guardava e mantinha em sua posse, para entrega a consumo de terceiros, 12 pedras de crack, 3 papéletes de maconha, e 1 microtubo de cocaína, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisório de fls. 18, auto de exibição e de apreensão de fl. 12, e imagens de fls. 13/17.

Sustenta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, o acusado corrompeu a adolescente Mara, de 15 anos, com ela praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes acima narrado.

Narra que policiais militares estavam em patrulhamento pela área após o recebimento de denúncia, dando conta de que um homem de outra cidade estava traficando pelos arredores do centro e da rodovia de Itariri. A equipe, ao se aproximar da rodovia, avistou a adolescente Mara acompanhada de dois indivíduos. Procedida à abordagem, foi localizada no bolso do acusado DIEGO a quantia de R\$ 100,00, em notas trocas. Com o adolescente Oseias nada de ilícito foi encontrado. Neste momento, a adolescente Mara se alterou, dizendo que “nela ninguém colocava a mão”. A adolescente, então, retirou de dentro de sua blusa os entorpecentes apreendidos. O acusado DIEGO disse, então, à equipe, que os entorpecentes eram seus, e que os tinha deixado com a adolescente por sua condição feminina. A equipe policial, por fim, conduziu todos à Delegacia de Polícia. É certo pelas circunstâncias da apreensão, em especial pela diversidade e quantidade de entorpecente apreendida, somada à quantia em moeda fracionada encontrada, que o denunciado visava o comércio ilícito de drogas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 47/49).

Notificado, o réu apresentou defesa (fls. 80/99) e a denúncia foi recebida (fls. 105/106).

Auto de constatação a fls. 18 e laudo toxicológico definitivo a fls. 132/134.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado nega a autoria delitiva, dizendo estar apenas comprando droga, com a intermediação da adolescente.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento parcial da pretensão acusatória, com a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de aumento do inciso VI do artigo 40, pelo princípio da especialidade, tudo diante da suficiência da prova colhida a respeito da destinação da droga ao comércio espúrio (fls. 215/221).

A defesa técnica (fls. 244/247) foi pela absolvição do acusado, ressaltando que ele é apenas usuário, inclusive de crack, o que é incompatível com o comércio da droga diante das regras próprias das organizações criminosas, subsidiariamente requerendo sua internação para tratamento da dependência química.

A folha de antecedentes atualizada foi acostada a fls. 121/125 e há certidão de distribuição a fls. 126/129.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

Com efeito, o policial Eder disse que estava em patrulhamento pela via pública, tendo recebido denúncia de diversos moradores de tráfico de droga nas imediações do bairro. Deparou-se com o indivíduo e dois adolescentes, um homem e uma mulher – esta já conhecida no meio policial. Fizeram a abordagem diante do nervosismo de DIEGO e, em revista pessoal, encontraram dinheiro e aparelho celular. A adolescente Mara estava nervosa, tentando se afastar da diligência antes que uma policial feminina pudesse realizar a revista. O outro adolescente disse que era usuário de drogas e informalmente confessou o uso. DIEGO, então, confessou que Mara guardava a droga para ele, pedindo que ela entregasse o entorpecente. Confessou, então, o comércio espúrio. Não conhecia DIEGO, apenas Mara que, em outra ocorrência, estava em companhia de outro indivíduo de fora da cidade. Foram encontrados crack, maconha e cocaína com Mara. As denúncias que chegaram, por 3 ou 4 moradores, noticiavam um indivíduo de fora comercializando drogas numa chácara já conhecida e, no dia anterior, já haviam abordado Mara voltando daquela região. Assim que o Conselheiro Tutelar chegou, Mara fez a entrega da droga. Não tinha receio de que Mara portasse uma arma de fogo diante do que conseguiam visualizar por cima da roupa. Não sabe se o microtubo de cocaína estava pela metade nem o motivo para tanto.

O policial Marcelo disse que havia recebido denúncias de moradores avistando usuários de droga na região e que um indivíduo de fora estava realizando o comércio, em razão do que fizeram patrulhamento no local. Junto com o indivíduo

estaria uma menor já conhecida da polícia, de outras diligências. Na ocasião, localizaram três indivíduos e, em revista, localizaram dinheiro e celular com DIEGO e o terceiro indivíduo disse que havia consumido droga. Mara estava inquieta e nervosa, dizendo que os policiais não poderiam colocar a mão nela, e a detiveram até a chegada do Conselho Tutelar e de uma policial feminina. Nesse instante, DIEGO confessou que Mara portava droga de sua propriedade e pediu para que ela a exibisse, o que ela fez. Efetuaram, então, a prisão de DIEGO e a apreensão de Mara. Havia denúncias de comércio de drogas na região, em alguma chácara que não sabiam ao certo onde. DIEGO não esboçou reação agressiva, mas apenas uma fala confusa devido ao fato de ter usado drogas. Não é comum que traficantes indiquem onde está a droga, mas, no caso, DIEGO deve ter percebido que era inevitável a busca em Mara uma vez chegando o Conselho Tutelar e a policial acionada. A denúncia de populares se deu nos dias anteriores e não diretamente a sua equipe – formada pelo cabo Eder. Tudo o que se soma à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal), confirmando que portasse consigo a droga apreendida. Contudo, segundo se crê, não há prova suficiente quanto a no sentido de que o destino da droga apreendida não fosse o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros. Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga.

No caso, a quantidade de droga apreendida é compatível com o que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, por até cerca de uma semana, e infirma a versão acusatória.

Depois, as circunstância da apreensão nada dizem sobre o destino da droga, porque não estava o acusado em conhecido ponto de venda de drogas, mas em rodovia, sem que as denúncias anônimas a que fizeram referência os agentes policiais tenham sido

específicas quanto à localização do ponto de venda. Não há outros indicativos de comercialização, o que não se pode extrair, tão só, da existência de dinheiro em espécie, no valor de R\$ 100,00, em seu poder.

O único elemento a corroborar a versão acusatória é o depoimento policial Eder a respeito do que, informalmente, teria dito o acusado quando da abordagem, mas o que é de todo insuficiente, porque isto não se confirmou em seu interrogatório policial ou judicial.

Aliás, a versão do acusado de que destinado a droga para o seu consumo pessoal é mesmo corroborada pelo depoimento do policial Marcelo, que notou fala pastosa, típica de quem fez uso há pouco de entorpecente. Também, no mesmo sentido, foi o depoimento do terceiro indivíduo que estava com DIEGO e Mara, Oseas, em seu depoimento nos autos da apuração de ato infracional (1500039-87.2022.8.26.0280). Ademais, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Não se está a duvidar da veracidade dos depoimentos prestados a este juízo por quem cumpre nobre e corajosa função no sistema de segurança pública em uma sociedade brasileira tão desigual e fragmentada, mas o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos.

Mutatis mutandis é o que levou o Superior Tribunal de Justiça a exigir mais do que a palavra dos agentes policiais para resultar válida a autorização de ingresso no domicílio, verbis: "7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado." (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Tal entendimento também foi sufragado pela Quinta Turma: HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021.

Crer que a palavra dos policiais envolvidos na formação da opinião delicti seja suficiente para a condenação desde que não infirmados ou refutados pela defesa é impor indevida inversão do ônus probatório, que é da acusação, e violar, por via transversa, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (cf. Aury Lopes Jr., Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529-530). Afinal, em última análise, o destino do acusado já estaria selado tão somente pela atuação do agente policial.

Em suma, a respeito deste elemento do tipo penal, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto a este

aspecto da responsabilidade penal do acusado. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão neste particular.

Adequação Típica

Como se disse, o quadro probatório evidenciou que o acusado praticou, de forma consciente e deliberada, a conduta de transportar e trazer consigo droga para consumo pessoal, nos exatos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Daí porque, nos termos do artigo 383, caput, do Código de Processo Penal, acolho em parte a pretensão acusatória e atribuo qualificação jurídica diversa à denúncia para reconhecer a prática do crime de porte para consumo pessoal.

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Observo que não há incompatibilidade entre o preceito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a Constituição Federal, mesmo que sob o pálio do princípio da alteridade. Não há dúvida de que o direito penal deve observar se nortear pelo princípio da alteridade ou transcendentalidade, mas o que é observado por esta norma penal, que não pune o consumo de drogas, mas o seu porte com destino ao consumo pessoal, assim com potencialidade de circulação, gerando um perigo à saúde pública.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilícitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilícitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, com as particularidades inerentes às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado ostenta maus antecedentes diante de sua condenação por crime do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em fevereiro de 2013, já decorrido o período depurador da reincidência.

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em

20/06/2005).

Os motivos do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As circunstâncias do crime, porém, devem ser valoradas negativamente ante o envolvimento de adolescente na prática delitiva, de resto o que levaria ao aumento da pena pelo crime do artigo 33 na forma do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social, desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias e neutras as demais circunstâncias.

É de rigor, ainda, a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal).

Assim, necessária e adequada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Regime inicial

Via de regra, realmente inviável a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Contudo, excepcionalmente na hipótese vertente, em que a sanção penal ao final aplicada é a de prestação de serviços à comunidade – e cujo descumprimento leva, em último caso, à imposição de multa –, impõe-se desde logo reconhecer a extinção da punibilidade pelo seu cumprimento por força da detração, diante do tempo de prisão, no regime fechado da preventiva, em razão deste processo.

Contabilizo, analogicamente, o equivalente a 1/3 do prazo da prestação de serviços em comparação ao tempo da prisão preventiva, assim cumprida a pena 1 mês após o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Efeitos secundários da condenação

Considerando demonstrado apenas a destinação ao consumo pessoal da droga, não há que se falar em perda do produto do crime, liberando-se o dinheiro apreendido em favor do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar DIEGO FERREIRA DA SILVA à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, pela prática do crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Em razão da detração, julgo extinta desde logo a punibilidade pelo cumprimento da pena imposta em 25 de fevereiro de 2022.

Por consequência, revogo a prisão preventiva antes decretada. Expeça-se com urgência alvará de soltura clausulado.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; e expeça-se a certidão de honorários ao

advogado dativo, se o caso.

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, cumprida a sanção penal de advertência, por escrito, com a intimação pessoal desta sentença, fica extinta a punibilidade respectiva. Anote-se e archive-se definitivamente.

Int.

Itariri, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA